

1502381-82.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... agravante em questão:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502381-82.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502381-82.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2207479/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19371765 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 1801/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2207479 - 04º D.P. LIMEIRA, 1801/21/923 - 04º D.P. LIMEIRA, 2207479/2021 - 4º Distrito Policial de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Robson Liocadio da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

ROBSON LIOCÁDIO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafos 1º (repouso noturno) e 4º, inciso II (escalada), do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, em 03 de agosto de 2021, por volta das 02h10min, na Rua Projetada, ao lado do nº 6252, bairro Jardim do Lago, neste município e comarca, o acusado subtraiu, para si, durante repouso noturno e mediante escalada, 01 morsa, cerca de 05 Kg de pedaços de fios de cobre, 01 faca e 01 turquez, que estavam no interior do referido imóvel (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 40/41).

Apurou-se que o denunciado, com manifesto intento de praticar crimes contra o patrimônio, pulou o muro da casa em construção situada no logradouro supra, adentrou o local e apoderou-se dos bens acima descritos, com os quais se evadiu.

Posteriormente, policiais militares avistaram ROBSON caminhando sobre uma ponte que liga os bairros Jardim do Lago e Odécio Degan, ocasião em que o o denunciado, ao visualizar os policiais, dispensou a mochila que trazia consigo e tentou retornar pelo caminho que fazia, momento em que os agentes públicos o abordaram.

Em revista pessoal, os policiais encontraram no interior da mochila os objetos subtraídos momentos antes. Ato contínuo, informalmente, o denunciado confessou a subtração dos bens e indicou o imóvel alvo da subtração, ocasião em que foi preso em flagrante delito

A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2021 (fls. 136).

O réu foi citado (fls. 146) e ofereceu a defesa preliminar (fls. 150).

O despacho de recebimento foi mantido (fls. 155).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, com interrogatório do réu ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 234/243) e da Defensoria Pública (fls. 247/254).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade restou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 36/38), auto de exibição e apreensão (fls. 43/44), fotografias de fls. 39/42, laudo pericial do local (fls. 162/166), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Na fase policial, o acusado desejou permanecer em silêncio (fls. 08).

Em Juízo, o réu disse que tem 34 anos. No dia dos fatos, andava pelas ruas do bairro e catava reciclagem. Viu a construção. Era um terreno vazio. Pulou o muro. Achou os fios e a morsa e delas se apoderou. A turquez era dele, assim como a faca. Colocou os bens numa mochila e foi embora. Depois foi abordado pelos policiais. Soltou a mochila e saiu andando antes de ser revistado. Foi enquadrado. Confirmou que jogou a mochila e nela havia objetos furtados da obra. Está arrependido. Não sabe o horário da abordagem. Havia furtado aqueles bens há meia hora antes da abordagem policial (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, em harmonia com a confissão judicial.

A vítima Paulo Batista contou que chegou pela manhã na construção. A fiação da obra, a morsa e uma turquez foram furtadas. Recuperou no distrito policial os bens

surrupitados. Trabalha no local até hoje. Falaram que uma pessoa foi detida em poder desses bens. A morsa vale em torno de quatrocentos reais, os fios duzentos reais e a turquez cinquenta reais. Recuperou todos os objetos furtados (mídia).

Em casos como o presente, a palavra da vítima que não conhecia o acusado e que não tinha qualquer intenção de prejudica-lo injustamente é de muito relevo.

“(...) Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância" (...) RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação 0000614-32.2017.8.26.0544; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

“Apelação - Furto qualificado - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas (...)Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação 1500443-59.2016.8.26.0536; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).

O policial militar Kaíque Bertoli Magro contou que faziam patrulhamento pelo bairro Odécio Degan e quando foram fazer abordagem de algumas pessoas avistaram o réu perto de uma ponte. Ele trazia consigo uma mochila, dispensando-a ao ver a viatura. Houve abordagem. Indagado, ele disse que achou aquele material contido numa mochila numa reciclagem. Foram ver o que havia sido dispensado. Havia uma turquez, uma morsa e fios. Indagado novamente, o indiciado confirmou a prática do furto e assim agiu para fazer uso de drogas. O acusado mostrou o local de onde furtou aqueles bens. Houve escalada. Deram voz de prisão. A abordagem foi no período da noite. Havia um cadeado trancando o local, ele pulou o muro e subtraiu os bens de um quartinho. O local é uma construção. O réu foi abordado há certa distância. No local há comércio e residências (mídia).

O policial militar Lucas Mateus Pereira disse que faziam patrulhamento pelo bairro Odécio Degan. Ao abordar certas pessoas, viram o acusado perto de uma ponte com uma mochila em seu poder. Ao ver a viatura, ele mudou a direção e soltou a mochila. Fizeram abordagem. Questionado, ele disse que achou os objetos no reciclado. Viram que era uma turquez, morsa e fios. Indagado novamente, ele confessou o furto para fins de uso de drogas. O acusado disse que ingressou mediante escalada. O local estava trancado. A abordagem foi de madrugada. O local era uma construção, o proprietário não estava. Foi o réu quem indicou o local do furto e apontou a subtração de um quartinho. Não havia pessoas repousando na construção (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada nenhuma agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não

mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo teor da prova oral colhida, o acusado, com o intuito de furtar, escalou um muro de uma construção e se apoderou dos bens que ali estavam.

Após subtrair os objetos, ele passou a caminhar pelas ruas do bairro, mas foi visto pelos policiais militares em patrulhamento de rotina. Ao presenciar a viatura, o réu dispensou a sacola contendo bens furtados e tentou caminhar para longe deles, sendo abordado.

No interior da mochila os guardas localizaram os objetos furtados. Indagado, apesar da hesitação inicial, o acusado confessou a prática do furto. Houve prisão em flagrante.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de furto imputado, cabendo lembrar que o acusado confessou a prática do delito patrimonial e foi detido em poder da res furtiva.

O delito de furto restou consumado. A consumação do crime em questão se dá com a posse sobre a coisa, ainda que por um breve espaço de tempo, não se exigindo que o agente consiga a posse mansa e pacífica, como antes se entendia. Trata-se, portanto, de adoção da teoria da amotio (cf. STJ, AgRg no REsp 1483770/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016).

A qualificadora de escalada restou configurada, tendo em vista a prova oral e técnica colhida. A fachada contém um muro de alvenaria com cerca de três metros de altura, havendo marcas de escalada (fls. 162/166).

Nem se alegue a insignificância da conduta, para sustentar sua atipicidade. A legislação penal brasileira não consagra o "princípio da insignificância" ou o da "bagatela". A ação do acusado envolveu bem que conta com valor economicamente apreciável, de réu reincidente e que provocou o furto mediante escalada, consolidando a tipicidade do ato também em sua dimensão material, conforme julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça que segue abaixo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias destacaram os maus antecedentes e a reincidência específica do réu - que ostenta duas condenações definitivas anteriores pelos crimes de furto e de roubo - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no AREsp 1673509/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. ALMEJADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO O

REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO ACUSADO. (...) II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável. III - In casu, não se tem como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, vale dizer, com quatro condenações já transitadas em julgado. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância (...)" (STJ, AgRg no HC 623.343/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE (...) 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004). 2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 3. Evidenciado que o recorrente, além de ser reincidente específico, é possuidor de maus antecedentes (e, ainda, em poucos dias praticou dois delitos contra o patrimônio em face da mesma vítima), resta demonstrada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, além de demonstrar o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico (...)" (STJ, AgRg no AREsp 1803543/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Portanto, não é recomendável ou justo premiar o réu com a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a res furtiva não tenha grande valor de mercado.

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o bem de valor insignificante. É imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Aquele, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se o princípio da insignificância. Este, eventualmente, pode caracterizar o privilégio inculcado no artigo 155, § 2º, do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da conduta.

Registre-se que eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade dos réus, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

"A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de

livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 358).

Por fim, não incide a causa de aumento de pena do furto noturno, apesar do entendimento em sentido contrário do julgador.

Em recente julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP).

Para tanto, adotou-se o entendimento de que a qualificadora do delito de furto é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da causa de aumento de pena. O legislador afastou a incidência da majorante em relação ao crime qualificado previstos no parágrafo 4º do artigo 155 do CP.

Em razão da interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado.

Logo, afasto a causa de aumento de pena do furto noturno.

Por fim, não é caso de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal. Não há provas de que o acusado tenha agido para se aproveitar da situação de calamidade pública causada pela pandemia de COVID-19. O crime de furto foi cometido em circunstâncias normais, motivo pelo qual afasto o reconhecimento da agravante.

A respeito do assunto, cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência da agravante em questão:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j,

do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

"Na hipótese, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em tese seria cabível em desfavor do paciente, em face da crise causada pela pandemia, de ordem, econômica, social e sanitária, já que o crime foi cometido na vigência do Decreto Legislativo 6/2020, de 20/03/2020. Todavia, a despeito da prática do crime em ocasião de calamidade pública e do desvalor, sem dúvida, da conduta do paciente, não é suficiente, a meu sentir, a existência do Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública para incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância, e isso não foi devidamente demonstrado na hipótese em análise. Ademais, como bem destacou o parecer ministerial às fls. 73, grifei "A despeito da maior censurabilidade da conduta praticada no período de calamidade pública, o referido evento, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, sob pena de responsabilização objetiva do agente." Por essas razões, entendo que deve ser afastada a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal(...)". (STJ, HC 632.019/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, julgado em 10/02/2021).

Demonstrada a parcial procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase, observando-se os elementos dos autos e aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são desfavoráveis, de modo que fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, já que o réu é portador de maus antecedentes (cf. fls. 48/57), ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no Resp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

O réu é reincidente específico (cf. fls. 48/57), mas por ter confessado a prática delitiva e demonstrado arrependimento, opero a compensação integral entre a agravante e a atenuante, mantendo a pena inicialmente fixada.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, ainda mais quando utilizada a atenuante para fundamentar a sentença condenatória.

Ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição, fixo a pena final em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em razão da quantidade de pena aplicada (inferior a 4 anos) e da reincidência, o regime inicial deverá ser o semiaberto, sob a luz do artigo 33, §3º, do Código Penal, levando-se em consideração ainda que o acusado confessou a prática delitiva.

Como o acusado é reincidente, sua folha demonstra que a imposição de medidas alternativas, como as penas restritivas de direitos, não trará o caráter preventivo da pena.

Sendo assim, afasto a possibilidade de substituição da pena corporal, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, por não se mostrar medida socialmente adequada.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, CONDENO o acusado ROBSON LIOCÁDIO DA SILVA, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no artigo 155, 4º, inciso II (escalada) do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, se não estiver preso em razão de outro processo, por força do regime inicial fixado, incompatível com a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura.

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o HC nº 181.534, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 02/03/2020, "eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado pelas instâncias ordinárias".

Na mesma direção:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário". (STF, HC 138122, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017).

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.



Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA